

刑法
No101

共通問題 R3-19

(配点: 2)

月 日
月 日

緊急避難に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 豪雨により稲苗が水に沈む危険が生じていたことから、排水のため他人の所有する下流の板堰を損壊した場合、「現在の危険」があるとは認められないので、緊急避難は成立しない。
- イ. 警察官の適法な逮捕行為に対し、逮捕を免れるためには他に方法がなかったのに、第三者を突き飛ばして逃走し、よって同人に傷害を負わせた場合、緊急避難が成立し得る。
- ウ. 頭に拳銃を突き付けられて、覚醒剤の自己使用を強要され、これを拒むことができず、自己に覚醒剤を注射して使用した場合、犯罪行為の強要の手段は「現在の危険」に当たらないので、緊急避難は成立しない。
- エ. 吊橋が腐朽し、通行の際の揺れにより通行者の生命、身体等に危険が生じていたため、ダイナマイトを使用して同吊橋を爆破したが、通行制限の強化等適当な手段、方法を講ずる余地があった場合、同爆破行為は、「やむを得ずにした行為」とは認められないので、緊急避難は成立しない。
- オ. 甲が飼う犬A（時価30万円相当）を連れて山道を散歩中、乙が設置していた害獣駆除用の罠（時価3万円相当）にAがかかり、その生命に危険が生じ、Aを保護するためには他に方法がなかったのに、その罠を損壊した場合、緊急避難が成立する（甲及び乙いずれにも過失がなかったものとする。）。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

№101	緊急避難	正答率 94%
共通R3-19	正解	5

ア 誤っている

大判昭8.11.30。緊急避難（37条1項）にいう「危難」の発生原因については、人の行為に限らず、自然現象、動物の動作なども広く含まれる。判例も、本記述と同様の事案において、現在の危難があるとしている。よって、豪雨により稲苗が水に沈む危険が生じていたことから、排水のため他人の所有する下流の板堰を損壊した場合、「現在の危難」があると認められるので、緊急避難が成立し得る。したがって、本記述は、豪雨により稲苗が水に沈む危険が生じていた場合、「現在の危難」があるとは認められないとしている点で、誤っている。

イ 誤っている

緊急避難（37条1項）の成立要件の1つとして、「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった」こと（法益の権衡）が要求されている。この要件を判断するに当たっては、一般的・抽象的な法益の価値が衡量されるのではなく、保全法益（回避された法益侵害）と侵害法益（惹起した法益侵害）とが具体的に比較衡量されなければならないとされている。本記述についてみると、逃走者は身体活動の自由に対する侵害を回避した一方、突き飛ばされた第三者は傷害を負っており、身体的安全（ひいては生理的機能）を害されているため、後者のほうが法益侵害の程度が高い。また、逃走者に対する逮捕行為は警察官による適法なものである一方、第三者は逮捕行為とは無関係であり、甲との関係で傷害結果を甘受すべき理由はないため、後者のほうが要保護性も高い。これらの事情を具体的に比較衡量すると、第三者に対する侵害法益が逃走者の保全法益を上回っており、「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった」ことの要件を満たさない。よって、本記述のような場合、緊急避難は成立し得ない（過剰防衛が成立し得るにとどまる。）。したがって、本記述は、警察官の適法な逮捕行為に対し、逮捕を免れるためには他に方法がなかったのに、第三者を突き飛ばして逃走し、よって同人に傷害を負わせた場合、緊急避難が成立し得るとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

東京高判平24.12.18（百選I31事件）。裁判例は、本記述と同様の事案において、緊急避難の成立を認めており、犯罪行為の強要の手段であっても「現在の危難」に当たり得ることを前提にしていると解される。裁判例の結論に賛成する学説は、その理由として、強要者側の悪質性を根拠に避難行為者を不利益に扱うべきではないということを挙げている。よって、本記述のような場合、緊急避難は成立し得る。したがって、本記述は、犯罪行為の強要の手段は「現在の危難」に当たらないので、緊急避難は成立しないとしている点で、誤っている。

エ 正しい

最判昭35.2.4（百選I30事件）。緊急避難（37条1項）の成立要件の1つである「やむを得ずにした」とは、補充性、すなわち、その危難を避けるための唯一の方法であって、他にとるべき方法がなかったことをいう（最大判昭24.5.18参照）ところ、判例は、本記述と同様の事案において、緊急避難の成立を否定している。その理由として判例は、吊り橋の腐朽具合は未だ切迫した危険ではなく「現在の危難」に当たらないことに加え、通行制限を強化するなど他の適当な手段・方法を講ずる余地があったのであり、ダイナマイトで爆破するのが唯一の方法とはいえず、補充性もないことなどを挙げている。よって、本記述のような場合、同爆破行為は「やむを得ずにした行為」とは認められないので、緊急避難は成立しない。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

大判昭 12.11.6。本記述では、緊急避難の成立要件のうち、法益の権衡の要件を満たすかが問題となる。価格 600 円相当の猟犬を救うために約 150 円相当の土佐雑種の番犬を殺害した事案において、判例は、緊急避難の成立を認めている。法益の権衡の有無については保全法益（回避された法益侵害）と侵害法益（惹起した法益侵害）とを具体的に比較衡量すべきである（肢イ解説参照）ところ、本記述では、甲は、時価 30 万円相当の飼い犬 A の生命侵害を回避した一方、乙が設置していた時価 3 万円相当の害獣駆除用の罠を損壊しており、前者のほうが法益侵害の程度が高いといえ、乙に対する侵害法益は甲の保全法益を上回っておらず、「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった」ことの要件を満たす。よって、本記述のような場合、緊急避難が成立する。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はエとオであり、したがって、正解は肢 5 となる。